

AGB-Kontrolle — Prüfungsschema §§ 305 ff. BGB

Allgemeines Schuldrecht — Zivilrecht (BGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Vorliegen Allgemeiner Geschäftsbedingungen, § 305 I BGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt (§ 305 I 1 BGB). Auf die äußere Form kommt es nicht an: Ob die Bedingungen einen gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden, in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen sind, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat, ist unerheblich (§ 305 I 2 BGB). Zu beachten sind die Bereichsausnahmen des § 310 IV BGB für Verträge auf dem Gebiet des Erb-, Familien- und Gesellschaftsrechts sowie für Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen; auf Arbeitsverträge sind die §§ 305 ff. BGB anwendbar, jedoch unter angemessener Berücksichtigung der im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten.

1. Vertragsbedingungen

Erforderlich ist eine Regelung, die den Inhalt des Vertragsverhältnisses gestalten soll. Bloße Hinweise, Wissenserklärungen, Leistungsbeschreibungen ohne regelnden Gehalt und reine Freundlichkeitsfloskeln sind keine Vertragsbedingungen; maßgeblich ist, ob die Bestimmung nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt Rechte und Pflichten der Parteien festlegt.

2. Vorformuliert

Die Bedingung muss für eine mehrfache Verwendung schriftlich oder in sonstiger Weise fixiert sein, bevor der Vertragstext im Einzelnen ausgehandelt wird. Es genügt, dass der Verwender die Klausel im Kopf hat oder aus einem Formularbuch, einer Textbausteinsammlung oder einer Datei abruft; auf eine Verkörperung im Vertragsdokument kommt es nicht an.

3. Für eine Vielzahl von Verträgen

Die Bedingungen müssen zur Verwendung in mindestens drei Verträgen bestimmt sein; nach herrschender Meinung genügt die entsprechende Absicht des Verwenders bereits bei der ersten Verwendung. Ob die Klausel tatsächlich mehrfach verwendet wurde, ist unerheblich — umgekehrt schadet es nicht, dass ein Dritter das Formular entworfen hat.

4. Stellen durch den Verwender

Stellen bedeutet, dass eine Partei die vorformulierten Bedingungen einseitig in den Vertrag einführt und ihre Einbeziehung verlangt. Verwender ist damit die Partei, die sich der vorformulierten Bedingungen zur Gestaltung des Vertrags bedient — nicht notwendig diejenige, die den Text verfasst hat. Wählen beide Parteien das Formular gemeinsam aus oder bringt es ein neutraler Dritter ein, fehlt es am Stellen.

5. Keine Individualabrede, § 305 I 3 BGB

AGB liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Parteien im Einzelnen ausgehandelt sind. Aushandeln verlangt mehr als Verhandeln: Der Verwender muss den gesetzesfremden Kerngehalt der Klausel inhaltlich ernsthaft zur Disposition stellen und dem anderen Teil Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener Interessen einräumen. Die bloße Erklärung, man könne über alles reden, oder das Ankreuzen einer von mehreren vorformulierten Alternativen genügt regelmäßig nicht.

6. Vorrang der Individualabrede, § 305b BGB

Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen — und zwar unabhängig davon, ob sie vor, bei oder nach Vertragsschluss und in welcher Form sie getroffen wurden. Eine der Individualabrede widersprechende Klausel ist deshalb nicht anwendbar; auch sogenannte Schriftformklauseln und doppelte Schriftformklauseln können den Vorrang nicht beseitigen.

7. Sonderregel für Verbraucherverträge, § 310 III BGB

Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher (§§ 13, 14 BGB) gelten AGB als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, sie wurden vom Verbraucher in den Vertrag eingeführt (§ 310 III Nr. 1 BGB). Nach § 310 III Nr. 2 BGB sind § 305c II BGB und die §§ 306, 307 bis 309 BGB auf vorformulierte Bedingungen auch dann anwendbar, wenn sie nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind, soweit der Verbraucher wegen der Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte — das Merkmal „Vielzahl von Verträgen“ ist dann entbehrlich. Nach § 310 III Nr. 3 BGB sind bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung zusätzlich die den Vertragsschluss begleitenden Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.

II. Einbeziehung in den Vertrag, § 305 II, III BGB

AGB gelten nicht kraft Gesetzes, sondern nur aufgrund rechtsgeschäftlicher Einigung. Gegenüber Verbrauchern und sonstigen Nichtunternehmern setzt die Einbeziehung die drei Voraussetzungen des § 305 II BGB voraus, die bei Vertragsschluss kumulativ vorliegen müssen.

1. Ausdrücklicher Hinweis, § 305 II Nr. 1 BGB

Der Verwender muss bei Vertragsschluss ausdrücklich auf die AGB hinweisen. Der Hinweis muss so deutlich sein, dass er auch bei flüchtiger Betrachtung nicht zu übersehen ist. Nur wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist — etwa bei Massengeschäften an Automaten oder Schaltern —, genügt ein deutlich sichtbarer Aushang am Ort des Vertragsschlusses.

2. Zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme, § 305 II Nr. 2 BGB

Der Verwender muss dem anderen Teil die Möglichkeit verschaffen, in zumutbarer Weise vom Inhalt der Bedingungen Kenntnis zu nehmen; eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung ist angemessen zu berücksichtigen. Erforderlich sind mühelose Lesbarkeit, verständliche Gliederung und zumutbarer Umfang; im elektronischen Geschäftsverkehr genügt regelmäßig ein Link, über den die Bedingungen abrufbar und speicherbar sind. Auf tatsächliche Kenntnisnahme kommt es nicht an.

3. Einverständnis der anderen Vertragspartei

Die andere Partei muss mit der Geltung der AGB einverstanden sein. Das Einverständnis kann ausdrücklich oder konkludent erklärt werden — etwa durch widerspruchsfreien Vertragsschluss nach ordnungsgemäßigem Hinweis. Schweigen auf eine erst nach Vertragsschluss übersandte Klausel oder auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben ist außerhalb des Handelsverkehrs kein Einverständnis.

4. Rahmenvereinbarung, § 305 III BGB

Die Parteien können die Geltung bestimmter AGB für eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften unter Beachtung der Anforderungen des § 305 II BGB im Voraus vereinbaren. Für die einzelnen Folgeverträge ist dann kein erneuter Hinweis erforderlich.

5. Überraschende und mehrdeutige Klauseln, § 305c I BGB

Bestimmungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil. Erforderlich sind objektive Ungewöhnlichkeit — eine deutliche Abweichung von den Erwartungen des typischen Vertragspartners — und ein Überraschungseffekt, der auch aus der Platzierung an versteckter Stelle folgen kann. § 305c I BGB gilt auch gegenüber Unternehmern.

6. Einschränkung im unternehmerischen Verkehr, § 310 I BGB

Gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen findet § 305 II und III BGB keine Anwendung (§ 310 I 1 BGB). Die Einbeziehung richtet sich dann nach den allgemeinen Regeln der §§ 145 ff. BGB; es genügt eine — auch stillschweigende — rechtsgeschäftliche Einigung, für die im Handelsverkehr regelmäßig ein erkennbarer Verweis auf die Bedingungen und die Möglichkeit zumutbarer Kenntnisverschaffung ausreichen. § 305c I

BGB und die Inhaltskontrolle nach § 307 BGB bleiben anwendbar.

7. Kollidierende AGB

Verweisen beide Parteien auf ihre eigenen, inhaltlich abweichenden Bedingungen, scheitert die Einbeziehung nicht insgesamt. Nach der heute herrschenden Theorie der Restgültigkeit gilt der Vertrag als geschlossen, soweit sich die Klauselwerke decken; im Übrigen tritt an die Stelle der widersprechenden Klauseln das dispositive Gesetzesrecht (§ 306 II BGB analog). Abwehrklauseln verhindern demgegenüber nur die Geltung der gegnerischen Bedingungen, nicht den Vertragsschluss.

III. Auslegung der Klausel

Vor der Inhaltskontrolle ist durch Auslegung zu ermitteln, welchen Inhalt die Klausel hat — nur eine ausgelegte Klausel kann am Maßstab der §§ 307 bis 309 BGB gemessen werden. Weil AGB für eine Vielzahl von Verträgen bestimmt sind, gelten Besonderheiten gegenüber den §§ 133, 157 BGB.

1. Objektive Auslegung

AGB sind nach ihrem objektiven Inhalt und typischen Sinn einheitlich so auszulegen, wie sie von verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen der normalerweise beteiligten Verkehrskreise verstanden werden. Individuelle Vorstellungen der konkreten Parteien bleiben außer Betracht; führt die Auslegung zu einem eindeutigen Ergebnis, ist für § 305c II BGB kein Raum.

2. Unklarheitenregel, § 305c II BGB

Zweifel bei der Auslegung gehen zu Lasten des Verwenders. Die Regel greift erst, wenn nach Ausschöpfung aller Auslegungsmethoden mindestens zwei vertretbare Auslegungsergebnisse verbleiben; bloße Auslegungszweifel im engeren Sinne genügen, nicht dagegen jede theoretisch denkbare Deutung.

3. Kundenfeindlichste Auslegung

Im Rahmen der Inhaltskontrolle ist nach herrschender Meinung zunächst die kundenfeindlichste Auslegung zugrunde zu legen, weil gerade sie die Unwirksamkeit der Klausel herbeiführt und den Kunden damit im Ergebnis am besten schützt. Erweist sich die Klausel danach als unwirksam, entfällt sie insgesamt; die kundenfreundliche Lesart wird nicht aufrechterhalten.

IV. Inhaltskontrolle, §§ 307 bis 309 BGB

Die Inhaltskontrolle setzt voraus, dass die Klausel überhaupt kontrollfähig ist; sodann ist die feste Prüfungsreihenfolge § 309, § 308, § 307 BGB einzuhalten — vom speziellsten zum allgemeinsten Maßstab. Wird die Klausel bereits von einem Klauselverbot erfasst, erübrigt sich die Generalklausel.

1. Eröffnung der Kontrollfähigkeit, § 307 III 1 BGB

Der Inhaltskontrolle unterliegen nur Bestimmungen, durch die von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Kontrollfrei sind daher deklaratorische Klauseln, die nur den Gesetzeswortlaut wiedergeben, sowie die Beschreibung der Hauptleistungspflicht und die unmittelbare Preisabrede — insoweit fehlt es an einem gesetzlichen Kontrollmaßstab, weil Leistung und Gegenleistung der Privatautonomie unterliegen. Kontrollfähig bleiben Preisnebenabreden, also Klauseln, die das Entgelt nur mittelbar beeinflussen, etwa Bearbeitungs- und Bereitstellungsentgelte oder Preisanpassungsklauseln.

2. Transparenzkontrolle auch kontrollfreier Klauseln, § 307 III 2 BGB

Auch Klauseln, die nach § 307 III 1 BGB der Inhaltskontrolle entzogen sind, können nach § 307 I 2 in Verbindung mit § 307 I 1 BGB wegen fehlender Klarheit und Verständlichkeit unwirksam sein. Leistungsbeschreibung und Preisabrede unterliegen damit zwar keiner Angemessenheits-, wohl aber einer Transparenzkontrolle.

3. Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit, § 309 BGB

Zuerst zu prüfen sind die Verbotstatbestände des § 309 BGB: Ist der Tatbestand erfüllt, ist die Klausel ohne jede Abwägung unwirksam. Praktisch bedeutsam sind insbesondere kurzfristige Preiserhöhungen (§ 309 Nr. 1 BGB), Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsverbote (§ 309 Nr. 2, 3 BGB), Vertragsstrafen (§ 309 Nr. 6 BGB), der Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei grobem Verschulden (§ 309 Nr. 7 BGB) und die Beschränkung von Mängelrechten (§ 309 Nr. 8 BGB).

4. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit, § 308 BGB

Anschließend ist § 308 BGB zu prüfen. Die Tatbestände enthalten unbestimmte Rechtsbegriffe wie „unangemessen lang“ oder „nicht hinreichend bestimmt“ und verlangen deshalb eine wertende Betrachtung des Einzelfalls; erfasst werden unter anderem Annahme- und Leistungsfristen (§ 308 Nr. 1 BGB), Änderungsvorbehalte (§ 308 Nr. 4 BGB) und Zugangs- und Erklärungsfiktionen (§ 308 Nr. 5, 6 BGB).

5. Generalklausel, § 307 I, II BGB

Unwirksam sind Bestimmungen, die den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Unangemessen ist eine Benachteiligung, wenn der Verwender missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten des Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne dessen Belange hinreichend zu berücksichtigen; maßgeblich ist eine typisierende Abwägung, bei Verbraucherverträgen ergänzt um die begleitenden Umstände nach § 310 III Nr. 3 BGB.

6. Regelbeispiele des § 307 II BGB

Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn die Klausel mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist (§ 307 II Nr. 1 BGB) — dazu zählt insbesondere das Prinzip der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung sowie die gesetzliche Risikoverteilung — oder wenn sie wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist (§ 307 II Nr. 2 BGB). Letzteres betrifft die sogenannten Kardinalpflichten, also die vertragswesentlichen Pflichten, deren Erfüllung den Vertrag überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut; ihre Haftung kann formularmäßig nicht ausgeschlossen, sondern allenfalls der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt werden.

7. Transparenzgebot, § 307 I 2 BGB

Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. Das Transparenzgebot verlangt, dass der Verwender Rechte und Pflichten seines Vertragspartners möglichst klar, einfach und präzise darstellt, wirtschaftliche Nachteile und Belastungen so weit erkennbar werden, wie es nach den Umständen gefordert werden kann, und die Klausel die Rechtslage nicht verschleiert — es umfasst damit ein Bestimmtheits-, ein Verständlichkeits- und ein Täuschungsverbot.

8. Ausnahmen und Modifikationen, § 310 I BGB

Gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen finden die Klauselkataloge der §§ 308, 309 BGB grundsätzlich keine Anwendung; die Kontrolle erfolgt allein über § 307 BGB, wobei auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche angemessen Rücksicht zu nehmen ist (§ 310 I 2 BGB).

V. Rechtsfolge, § 306 BGB

§ 306 BGB verdrängt als Sonderregel den § 139 BGB: Die Unwirksamkeit einer Klausel führt gerade nicht zur Nichtigkeit des gesamten Vertrags.

1. Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen, § 306 I BGB

Sind AGB ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Betroffen ist nur die einzelne Klausel; § 139 BGB ist nicht anwendbar.

2. Lückenfüllung durch dispositives Recht, § 306 II BGB

An die Stelle der unwirksamen Klausel treten die gesetzlichen Vorschriften. In der Klausur ist deshalb nach Feststellung der Unwirksamkeit stets das dispositive Recht heranzuziehen — etwa die gesetzlichen Mängelrechte, die Verjährungsfristen der §§ 195, 438 BGB oder der Haftungsmaßstab des § 276 BGB.

3. Ergänzende Vertragsauslegung

Nur wenn das dispositive Recht keine sachgerechte Lösung bereithält und der Vertrag ohne Ergänzung nicht durchführbar wäre, kommt ausnahmsweise eine ergänzende Vertragsauslegung nach §§ 133, 157 BGB in Betracht. Sie darf nicht dazu dienen, der unwirksamen Klausel doch noch zu einem zulässigen Restinhalt zu verhelfen.

4. Unzumutbare Härte, § 306 III BGB

Der Vertrag ist ausnahmsweise insgesamt unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter Berücksichtigung der nach § 306 II BGB vorgesehenen Änderung für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Der Verwender kann sich hierauf nach herrschender Meinung regelmäßig nicht berufen, weil er die unwirksame Klausel selbst gestellt hat.

5. Keine geltungserhaltende Reduktion

Eine unwirksame Klausel wird nicht auf das gerade noch zulässige Maß zurückgeführt, sondern entfällt vollständig. Andernfalls könnte der Verwender risikolos überzogene Klauseln stellen, weil ihm im Streitfall stets das rechtlich Zulässige verbliebe; das Verbot dient damit der Präventionsfunktion der §§ 305 ff. BGB.

Typische Streitstände

Blue-Pencil — Verbot der geltungserhaltenden Reduktion und Blue-Pencil-Test

Nach ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre ist eine geltungserhaltende Reduktion unzulässig: Eine gegen §§ 307 bis 309 BGB verstoßende Klausel entfällt vollständig und wird nicht auf den gerade noch zulässigen Inhalt zurückgeführt, weil der Verwender sonst ohne Risiko überzogene Bedingungen stellen könnte und die Präventionswirkung des AGB-Rechts leerläufe. Davon zu unterscheiden ist der Blue-Pencil-Test: Enthält eine Regelung mehrere sprachlich und inhaltlich voneinander trennbare Bestandteile, ist nur der unwirksame Teil zu streichen; der verbleibende Rest bleibt wirksam, wenn er auch ohne den gestrichenen Teil aus sich heraus verständlich und sinnvoll ist. Maßgeblich ist die inhaltliche Teilbarkeit, nicht die äußere Gestaltung — eine sprachlich einheitliche, inhaltlich untrennbare Klausel fällt vollständig weg, weshalb Klauselwerke die Tatbestände regelmäßig in getrennten Sätzen fassen.

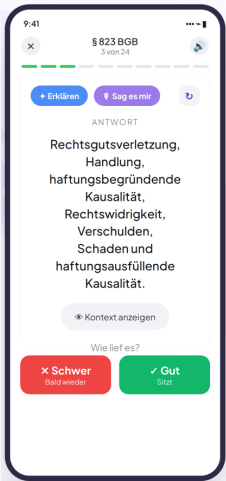
Indizwirkung — §§ 308, 309 BGB im unternehmerischen Verkehr

Nach § 310 I 1 BGB gelten die Klauselkataloge der §§ 308, 309 BGB gegenüber Unternehmern nicht unmittelbar; nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt ihnen im Rahmen der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB jedoch Indizwirkung zu: Verstößt eine Klausel gegen ein Klauselverbot, indiziert dies auch im unternehmerischen Verkehr eine unangemessene Benachteiligung. Die Indizwirkung ist widerleglich — nach § 310 I 2 BGB ist auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche angemessen Rücksicht zu nehmen, sodass die geringere Schutzbedürftigkeit des Unternehmers und branchenübliche Gepflogenheiten die Angemessenheit im Einzelfall begründen können. Eine Gegenauffassung lehnt die pauschale Übertragung ab und verlangt in jedem Fall eine eigenständige Abwägung nach § 307 BGB, weil die Kataloge auf den Verbraucherschutz zugeschnitten seien; in der Klausur ist jedenfalls gesondert zu begründen, warum die Wertung des Katalogtatbestands auch zwischen Unternehmern trägt.

Transparenz — Reichweite des Transparenzgebots, § 307 I 2 BGB

Anerkannt ist, dass das Transparenzgebot über § 307 III 2 BGB auch für Klauseln gilt, die der Angemessenheitskontrolle entzogen sind — insbesondere für Leistungsbeschreibungen und Preisabreden —, und dass ein Verstoß für sich genommen die Unwirksamkeit begründet, ohne dass es zusätzlich einer

inhaltlichen Benachteiligung bedarf. Umstritten ist die Grenze: Nach herrschender Meinung muss der Verwender die wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen nur so weit erkennbar machen, wie es nach den Umständen gefordert werden kann, gemessen am Verständnis eines durchschnittlichen Vertragspartners des angesprochenen Verkehrskreises; eine strengere Auffassung will jede Klausel bereits dann als intransparent verwerfen, wenn sie ohne juristische Vorkenntnisse nicht vollständig erfasst werden kann. Gegen die strenge Sicht spricht, dass komplexe Vertragsverhältnisse ohne rechtstechnische Begriffe nicht regelbar sind; die bloße Verwendung von Gesetzesziten oder Fachbegriffen macht eine Klausel daher noch nicht intransparent.



9:41 § 823 BGB 3 von 24

Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer
Sag es mir

Gut
Sag es mir



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.